

1500804-20.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores e realizou tráfico sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500804-20.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação  
de Prisão em Flagrante - 2007028/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22339882 - 72º D.P.  
VILA PENTEADO, 2007028 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON CAVALCANTE DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CLAYTON CAVALCANTE DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), na manhã de 08 de janeiro de 2022, por volta das 11h00min, na Travessa Itaipava, nº 137, bairro Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo, foi surpreendido trazendo consigo, para o tráfico de drogas, 78 (setenta e oito) porções de tetraidrocanabinol, conhecido como maconha; 106 (cento e seis) porções de cocaína em pó; 85 (oitenta e cinco) porções de cocaína na forma de crack e 5 (cinco)

frascos contendo tricloroetileno, conhecido como lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que segundo apurado, o denunciado trazia consigo as porções de drogas que seriam vendidas para compradores indeterminados, as quais eram mantidas ocultas entre uma telha e um portão, no local dos fatos, ao seu alcance e para sua pronta disponibilidade.

Relata a inicial que na ocasião dos fatos, o denunciado foi flagrado e abordado por policiais militares enquanto ocultava uma sacola plástica no esconderijo acima descrito.

Narra a exordial que durante a abordagem, as porções de drogas foram localizadas na mencionada sacola plástica, todas fracionadas e prontas para entrega ao consumo de terceiros, acompanhada de anotações alusivas à contabilidade do tráfico. No bolso do denunciado também foi localizada a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) em espécie. Segundo a acusação, indagado, CLAYTON confessou aos milicianos que estava comercializando drogas no local desde as 7h00, e que receberia R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia.

Interrogado pela Autoridade Policial, o acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas (fl. 13).

Por decisão exarada em 09 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 49/52).

A Defesa constituída nos autos (fl. 94) apresentou resposta à acusação (fls. 87/93).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 19 de janeiro de 2022 (fl. 98).

Aos 25 de janeiro de 2022, foi concedida a liberdade provisória ao acusado, subordinada, porém, à observância de algumas medidas cautelares alternativas (fls. 109/111).

Foi expedido alvará de soltura clausulado em benefício do réu (fl. 115), que posteriormente foi colocado em liberdade (fls. 118/119).

O acusado foi citado e intimado (fls. 120/121).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, a fixação de pena em regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação (fls. 24/27), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 129/131), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Fabio Aparecido Lira, policial militar, narrou, em síntese, que se recorda do réu. Estavam em patrulhamento e a rua Itaipava é conhecida pelo tráfico de drogas. O réu estava de costas colocando algo no telhado. Com o réu foi encontrado R\$ 5,00 no bolso. Encontraram a bolsa com drogas e o réu confessou, dizendo que estava arrependido. Tinha maconha, cocaína, crack e vidros com lança-perfume. Se não se engana o réu mencionou que receberia R\$ 150,00 pela diária, período de 12 horas.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Gustavo da Silva Oliveira, policial

militar, que narrou, em suma, que lembra-se do réu. Não conhecia o réu antes da ocorrência. Estavam em patrulhamento pela rua Itaipava e lá é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Avistaram o réu de forma desatenta colocando uma sacola preta entre um telhado e um portão. Fizeram a abordagem e em revista pessoal encontraram uma quantia baixa em dinheiro e no interior da sacola preta constataram certa quantidade de entorpecentes. Eram porções fracionadas de maconha, tinha cocaína, crack e lança perfume. O réu falou que estava na mercancia dos entorpecentes, pediu desculpa. O réu falou que ganharia R\$ 150,00 por turno trabalhado.

Ao ser interrogado em juízo, CLAYTON confessou a prática delitiva. Narrou que está com 26 anos de idade. Mora com a esposa e a filha, de 3 anos de idade. Começou a trabalhar fazendo "bicos" em obras e vendendo balas nos faróis. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. O que os policiais militares falaram é verdade. Estava precisando e o menino falou se o interrogando queria trabalhar. Iria ganhar R\$ 150,00 para vender as drogas.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína, crack e lança-perfume); b) pela considerável quantidade de drogas, incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, de modo a atingir diversos consumidores; d) pela apreensão de anotações; e) pela apreensão de R\$ 5,00 (cinco reais) em espécie; f) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a

demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente que possa ser considerado desabonador. No entanto, a quantidade de droga apreendida, bem como a variedade e natureza dos entorpecentes (maconha, cocaína, crack e tricloroetileno) deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal cominado, registrando-se que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nestes termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de dois terços, chegando ao resultado de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e seiscentos e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores e realizou tráfico sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos).

Da substituição da pena

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo

44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado CLAYTON CAVALCANTE DE SOUSA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 5,00)

em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA